

告訴に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例に照らして、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

- ア、弟甲から宝石を盗まれたとして同居していない姉Aが告訴した。捜査の結果、甲が宝石と一緒に現金を盗んでいたことが判明したが、Aは追加の告訴をしなかった。この場合、検察官が宝石と現金を窃取した事実で甲を起訴しても、親告罪について告訴のない事実を起訴したことにならない。
- イ、弟甲から宝石を盗まれたとして同居していない姉Aが告訴したが、後に告訴を取り消した。捜査の結果、甲が宝石と一緒に現金を盗んでいたことが判明したため、Aはこの現金を窃取した事実を告訴した。この場合、検察官が現金を窃取した事実で甲を起訴しても、親告罪について告訴のない事実を起訴したことにならない。
- ウ、弟甲から宝石を盗まれたとして同居していない姉Aが告訴した。捜査の結果、甲が宝石と一緒にAと同居している妹Bからも現金を盗んでいたことが判明したが、Bは告訴しなかった。この場合、検察官が宝石と現金を窃取した事実で甲を起訴しても、親告罪について告訴のない事実を起訴したことにならない。
- エ、胸を触られ強姦されそうになったことは許せない旨の強姦未遂の告訴を被害者から受けて捜査をした結果、強制わいせつの事実が判明した場合、被害者による強姦未遂の告訴は、それより軽い強制わいせつの事実を当然包含しているから、検察官が強制わいせつの事実で起訴しても、親告罪について告訴のない事実を起訴したことにならない。(解答不能)
- オ、深夜無理やり自動車に連れ込まれ強姦されそうになったことは許せない旨の強姦未遂の告訴を被害者から受けて捜査をした結果、わいせつ目的略取未遂の事実が判明した場合、強姦未遂罪とわいせつ目的略取未遂罪は、観念的競合又は牽連犯の關係に立ち、一方が他方を包含する關係にないが、被害者による強姦未遂の告訴があれば、検察官がわいせつ目的略取未遂のみの事実で起訴しても、親告罪について告訴のない事実を起訴したことにならない。(解答不能)
1. ア イ 2. ア エ 3. イ ウ 4. ウ オ 5. エ オ

*平成29年刑法改正により、強制性交未遂罪(旧強姦未遂罪)、強制わいせつ罪、わいせつ目的略取未遂罪は非親告罪に変更されたため、記述エ及びオは、改正法における出題として不適切なものとなった。

なお、令和5年刑法改正により、強制性交未遂罪は不同意性交未遂罪、強制わいせつ罪は不同意わいせつ罪に改められた。

No.33

H24-24

告 訴

正 解

3

正答率

40%

ア 正しい

本記述では、同居していない姉Aから宝石と現金を盗んだ行為が親告罪（刑法244条2項）に当たるところ、宝石の窃盗については告訴があるが、現金の窃盗については告訴がないことから、親告罪について告訴のない事実を起訴したことになるかが問題となる。明文の規定はないが、単一の犯罪の一部分についてした告訴は、当然残りの部分に対しても効力を生ずる（告訴の客観的不可分）。その趣旨は、告訴をする場合、通常訴追の範囲を犯罪の一部に限定する意思はないであろうし、被害者等に事件の分割を許すべきではないという点にある。そして、包括一罪の場合においても、単一の犯罪であるから、犯罪行為全体について包括的に評価すべきであり、この原則が当てはまる。本記述の宝石と一緒に現金を盗む行為は包括一罪に当たり、宝石の窃盗に対する告訴の効力は現金の窃盗について及ぶ。よって、本記述では、親告罪について告訴のない事実を起訴したことにならない。したがって、本記述は正しい。

イ 誤っている

237条2項。本記述では、姉Aは現金の窃盗につき告訴しているものの、先に宝石の窃盗についての告訴を取り消していることから、親告罪につき告訴のない事実を起訴したことになるかが問題となる。告訴の取消をした者は、更に告訴をすることができない（237条2項）。その趣旨は、自己が一旦した告訴を取り消しておきながら、さらに同じ犯罪事実について重ねて告訴をすることを認めることは、私人の恣意により国家刑罰権の行使を左右し、ひいては告訴権の濫用を招くおそれがあるため、これを禁止するという点にある。本記述では、宝石と一緒に現金を盗む行為は包括一罪に当たり、宝石を窃盗した事実に対する告訴の取消しの効力は現金を窃盗した事実についても及んでいる（告訴の客観的不可分）。よって、本記述では、Aは現金を窃盗した事実について更に告訴することはできない。したがって、本記述は、親告罪について告訴のない事実を起訴したことにならないとしている点で、誤っている。

ウ 誤っている

本記述では、甲が同居していない妹Bから現金を盗んだ事実は親告罪（刑法244条2項）であり、これについてBは告訴しておらず、同居していない姉Aのみが告訴しているが、Aの告訴の効力が一緒に盗まれた同居していないBの現金の窃盗の事実に及ぶかが問題となる。親告罪が設けられた趣旨は、被害者意思の尊重という点にある。そこで、被害者が複数いる親告罪について、被害者の一部だけが告訴した場合については、その告訴は、告訴をした者に関する事実についてのみ効力を有し、告訴をしなかった者に関する犯罪事実には及ばないと解されている。また、裁判例も、「親告罪である名誉棄損罪において、被害者の一部が告訴した場合、その告訴した被害者に対する犯罪についてのみ告訴が有効で、告訴をしない他の被害者に関係する部分にまで右の告訴の効力は及ぼさない」（名古屋高判昭30.6.21）としている。本記述では、Aによる宝石の窃取についての告訴は、告訴のないBの現金の窃取については、効力が及ばない。よって、本記述では、検察官が宝石と現金を窃取した事実で甲を起訴したことは親告罪について告訴のない事実を起訴したことになる。したがって、本記述は、親告罪について告訴のない事実を起訴したことにならないとしている点で、誤っている。

エ 出題として不適切なものとなった

平成29年刑法改正により、強制性交未遂罪、強制わいせつ罪は非親告罪に変更されたため、改正法における出題として不適切なものとなった。なお、告訴一般の問題として、明文の規定はないが、単一の犯罪の一部分についてした告訴は、当然残りの部分に対しても効力を生ずる（告訴の客観的不可分）。また、旧法下での裁判例も、強姦未遂の告訴に対し、強制わいせつ罪を認定した事案において、「強姦未遂の告訴中には之より軽い強制猥褻の事実は当然包含せられている。従つて強姦未遂の告訴があつた場合裁判所は被告人には姦淫の意思なく単に暴行を以つて告訴人に対し猥褻行為をした事実であると判定してこれを強制猥褻罪に間擬しても不法ではない。」（高松高判昭27.4.24）としている。

オ 出題として不適切なものとなった

平成29年刑法改正により、強制性交未遂罪、わいせつ目的略取未遂罪は非親告罪に変更されたため、出題として不適切なものとなった。なお、告訴一般の問題として、明文の規定はないが、単一の犯罪の一部分についてした告訴は、当然残りの部分に対しても効力を生ずるのが原則である（告訴の客観的不可分）。しかし、刑事政策的観点から一罪として扱われるにすぎない科刑上一罪の場合には、本来的には数罪であることとの関係から、親告罪の設けられた趣旨を重視すべきである場合には告訴の客観的不可分の原則が例外的に及ばないと解されている。すなわち、科刑上一罪の一部に限定された告訴の効力は、告訴の客観的不可分の原則が及ばず、他の部分には告訴の効力が及ばないが、告訴が限定の意思を明示しないでなされた場合には、原則通り他の部分にも告訴の効力が及ぶこととなる。また、旧法下での裁判例も、強制わいせつの犯行が、わいせつの目的をもって誘い出したその場所において行われた事案において、「その猥褻誘拐と強制猥褻とは通常手段、結果の關係にあり、従つて刑法第54条第1項後段で規定する牽連犯の關係にあるものと解せられるので、告訴不可分の原則により、前記告訴の効力は強制猥褻の事實にも及んでいるものと考えられる」（東京高判昭45.12.3）としている。

以上により、誤っている記述はイとウであり、したがって、正解は肢3となる。

なお、令和5年刑法改正により、強制性交未遂罪は不同意性交未遂罪、強制わいせつ罪は不同意わいせつ罪に改められた。

